

1500834-83.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudia Calles Novellino Ballesterio

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... réu é acusado dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso permitido.

Inquiridos quando da lavratura do flagrante, os policiais militares Milton Alexandre Ferreira dos Santos e Felipe Viana Sanches Silva narraram que realizavam operação policial no bairro Chácara Silvestre com o objetivo de coibir o intenso tráfico de drogas da localidade. Quando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

1ª Vara Criminal

PRAÇA MONSENHOR SILVA BARROS S/N

CENTRO - TAUBATÉ/SP - CEP 12020-070

FONE: (12) 3631-3040 - E-MAIL: TAUBATE1CR@TJSP.JUS.BR

Processo nº 1500834-83.2021.8.26.0618 - /

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500834-83.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor

Réu

Justiça Pública

Luiz Fernando Junior Alves dos Santos

Réu Preso

Vistos.

Luiz Fernando Júnior Alves dos Santos foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está sendo processado por incursão no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, porque no dia 09 de junho de 2021, por volta de 20h45min, na Rua Francisco Faria Júnior, altura do nº 1088, bairro Parque Três Marias, nesta cidade e comarca de Taubaté, trazia consigo, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes determinadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Ainda, portava e detinha munição de arma de fogo de uso permitido.

Descreve a denúncia que o réu estava na via pública referida e, ao perceber a aproximação de policiais militares, tentou deixar o local e dispensar a pochete que tinha consigo, chamando a atenção dos policiais, que o abordaram. A pochete foi localizada e verificou-se que continha 39 (trinta e nove) porções de maconha e 143 (cento e quarenta e três) porções de cocaína acondicionadas em tubos plásticos pequenos, além de uma munição de calibre 9mm e a quantia de R\$ 910,05, produto da venda anterior de entorpecentes (fls. 59/61).

Na decisão que recebeu a denúncia, datada de 07 de julho de 2021, deferiu-se o acesso a todas as informações constantes da memória do aparelho de telefonia celular apreendido (fls. 63/66).

O réu foi citado (fls. 86) e apresentou resposta escrita à acusação, em que impugnou a pretensão acusatória (fls. 98/99). Assentou-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu, em atendimento à determinação constante do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em três oportunidades diversas (fls. 93, 141 e 205).

Saneado o processo (fls. 112/114), realizou-se audiência de instrução por teleconferência mediante utilização da plataforma Microsoft Teams, cujo registro audiovisual foi salvo no sistema informatizado SAJ-PG5, oportunidade em que se procedeu à inquirição das testemunhas do rol acusatório, comuns à defesa, e ao interrogatório do réu (fls. 182/183).

Após a juntada aos autos da mídia contendo a compilação dos dados constantes do celular apreendido e periciado (fls. 186/187), as partes apresentaram alegações finais escritas.

O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, sustentando serem inverossímeis as alegações do réu sobre a procedência e destinação das drogas e de que não conhecia o adolescente que estava consigo quando da abordagem. Postulou o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais em razão da quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas; o afastamento da atenuante da confissão, ante a suficiência probatória e a tentativa de o réu minimizar sua autoria; que não seja aplicado o benefício do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 ante o envolvimento habitual do réu com práticas criminosas; seja reconhecido o concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de munição; a cominação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, considerando a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais negativas (fls. 192/202).

Já a Defesa pugnou pela absolvição do réu quanto ao crime de porte ilegal de munição, nos termos do art. 386, inc. III do Código de Processo Penal, ante a atipicidade material da conduta e segundo o princípio da insignificância. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação das penas-base nos mínimos legais e a cominação de regime inicial aberto de cumprimento de pena. Quanto ao tráfico de drogas, reconhecendo ser incontroversa a autoria do delito, pois confessada pelo próprio réu, concentrou suas postulações na dosificação das penas: pleiteou a fixação das penas-base nos mínimos legais, ante a primariedade do réu e ausência de maus antecedentes, além dos fatos não se revestirem de gravidade que extrapole a já inerente ao crime; a incidência da atenuante da confissão espontânea; o reconhecimento do privilégio, em face da inexistência de provas de que o réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa; a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena, e que a privação de liberdade seja substituída por restrição de direitos (fls. 211/220).

É o relatório.
Decido.

O réu é acusado dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso permitido.

Inquiridos quando da lavratura do flagrante, os policiais militares Milton Alexandre Ferreira dos Santos e Felipe Viana Sanches Silva narraram que realizavam operação policial no bairro Chácara Silvestre com o objetivo de coibir o intenso tráfico de drogas da localidade. Quando ingressaram no local dos fatos visualizaram o réu e o adolescente VCRS, que ao notarem a aproximação das viaturas saíram caminhando apressadamente em atitude suspeita, seguindo para direções diversas. Observaram que o réu arremessou uma pequena bolsa do tipo pochete no chão, motivo pelo qual realizaram sua abordagem. No interior da bolsa dispensada pelo réu localizaram 39 porções de maconha, 143 tubos cônicos contendo cocaína, 1 munição de

arma de fogo de calibre 9mm e a quantia de R\$ 910,00. Em posse do adolescente havia R\$ 30,00. Questionados, o réu e o adolescente permaneceram em silêncio. Segundo o PM Milton, a genitora do adolescente disse, informalmente, já ter ciência, por terceiros, de que o filho estava traficando drogas (fls. 07 e 08, respectivamente).

Também em juízo os policiais militares descreveram que realizavam patrulhamento em razão do tráfico de drogas que vinha ocorrendo no bairro Chácara Silvestre e, ao adentrarem na rua dos fatos viram que o réu e o menor VCRS estavam parados, mas quando avistaram a viatura policial, dispensaram uma bolsa preta e saíram andando em direções opostas, o que despertou suspeita na equipe. Embora o PM Milton já não se recordasse se chegou a visualizar que foi o réu quem dispensou a pochete, nem se ele apresentou alguma justificativa para sua conduta, o PM Felipe afirmou que o réu e o adolescente estavam próximos, mas foi possível identificar que quem dispensou a bolsa foi o primeiro, o que reiterou ao ser novamente indagado. O réu e o menor percorreram curta distância até que foram abordados. Nada de ilícito havia em seu poder. Os policiais retornaram e encontraram a pochete, na qual havia drogas (maconha e cocaína, segundo o PM Felipe), uma munição de arma de fogo e dinheiro (cerca de R\$ 900,00, segundo o PM Felipe).

Em acréscimo, disse o PM Felipe que durante a abordagem o réu e o adolescente alegaram que estavam apenas conversando, mas na Delegacia de Polícia a mãe do menor comentou ter conhecimento, por meio de pessoas da rua, que ele realizava o tráfico de drogas no local, nada referindo sobre o réu.

Já durante o trâmite da ação penal o adolescente VCRS não mais foi localizado e não prestou depoimento em juízo. Em sede policial narrou que se encontrava com o réu próximo à sua residência quando repentinamente surgiram viaturas da polícia e os abordaram. Em seguida, os policiais encontraram uma bolsa contendo drogas, atribuindo a ele e ao réu a sua propriedade. Alegou desconhecer a origem do entorpecente e negou que estivesse realizando o tráfico de drogas. Em seu poder foi encontrado apenas seu aparelho celular e a quantia de R\$ 10,00 (fls. 09).

O réu permaneceu em silêncio ao ser interrogado pela autoridade policial (fls. 12). Já em juízo confessou a prática delitiva, embora mediante versão pouco verossímil. Primeiramente narrou que estava com a namorada em frente à casa dela, no bairro Parque Três Marias (Rua Benedito Marques nº 413), quando um indivíduo de motocicleta - que conhece apenas por "Castor" - apareceu e lhe ofereceu dinheiro para que levasse drogas até o local dos fatos (Rua 06), no bairro Chácara Silvestre. Novamente indagado, inverteu as localidades, dizendo que foi preso no bairro Chácara Silvestre e estava levando as drogas para o bairro Parque Três Marias, onde uma pessoa de blusa vermelha o estaria esperando e ele receberia o dinheiro da contrapartida pela conduta. Depois, mais uma vez descreveu a primeira situação referida (recebimento das drogas no bairro Parque Três Marias para entrega no bairro Chácara Flórida), mantendo a narrativa de que uma pessoa de vermelho o estaria esperando para receber as drogas e lhe pagar a quantia de R\$100,00. Não conseguiu se deslocar ao local, nem receber a quantia, devido à abordagem. Afirmou que dispensou a bolsa quando viu os policiais por medo; desconhecia o tipo e a quantidade de drogas que havia na bolsa, assim como nada sabia a respeito da munição e do dinheiro que nela estavam; além da bolsa, nada mais havia em seu poder. Foi "burro" por assim agir, mas o fez por necessidade financeira. Alegou ter sido a primeira vez que praticou essa modalidade de conduta. Disse que não conhece o menor, o qual estaria perto dele "na hora errada". Trabalhava como pintor, mas devido à pandemia ficou desempregado e passava por necessidades financeiras. Não tinha envolvimento anterior com o tráfico de drogas.

Portanto, o réu não negou a posse das drogas e sua destinação ao tráfico, mas apresentou narrativa com que buscou evidenciar que se tratou de oportunidade única e circunstancial em que se envolveu com a traficância, a qual, entretanto, é questionável e se mostrou incoerente. Com efeito, foge à normalidade que alguém

seja abordado por uma pessoa que conhece apenas de vista, em ocasião em que está com a namorada, e seja solicitado a levar uma bolsa, com conteúdo não integralmente conhecido, para outro bairro e para uma pessoa que não sabe quem é, descrita apenas pela cor da roupa que vestia, havendo na bolsa, além de considerável valor em drogas, a elevada quantia de quase mil reais, mediante promessa de pagamento de importância que se pode reputar mínima frente ao valor do objeto do transporte e o risco de abordagem – que de fato ocorreu. Além disso, ao ser indagado mais de uma vez a respeito de sua conduta, o réu se contradisse em juízo ao inverter as localidades onde estava e para onde levaria as drogas, situação que ordinariamente ocorre quando se tenta distorcer os fatos.

Na hipótese, infere-se que o réu buscou minimizar a gravidade de sua conduta tentando desassociar de sua propriedade os objetos e produtos de ilícito, apresentando-se como seu mero e circunstancial detentor.

Reforça a incongruência do réu sua negativa sobre conhecer o adolescente que foi abordado em sua companhia, o qual afirmou que conhecia o réu e que estavam juntos quando da abordagem (fls. 09), o que se corrobora pelo fato dos policiais militares terem visualizado o réu e o adolescente inicialmente juntos, os quais apenas se dispersaram após avistarem a viatura policial.

E foi justamente essa conduta do réu e do menor, de se separarem e caminharem cada qual para uma direção, aliada à dispensa da pochete por parte do réu - o que ele confirmou ter efetuado, pois ciente de que continha drogas -, que gerou suspeita e ensejou a abordagem policial. Ademais, ambos estavam em conhecido ponto de tráfico de drogas.

O adolescente negou vínculo com os entorpecentes, mas de acordo com o PM Felipe, informalmente a mãe dele afirmou, na delegacia, que já tinha ciência por meio de terceiros de que o filho estava realizando o tráfico de drogas, nada referindo, contudo, sobre a pessoa do réu.

Com o adolescente foi localizada a quantia de R\$ 30,00 em dinheiro e um aparelho celular, no qual foi realizada perícia técnica (Laudos Periciais a fls. 104/107 e 108/110 e Relatório de Investigação relacionado à análise do conteúdo do celular a fls. 165/173).

Do celular, pertencente ao menor VCRS (fls. 166), não foi possível extrair o conteúdo de conversas pelo aplicativo WhatsApp (fls. 167), mas nele havia imagens de substâncias que podem ser entorpecentes e mensagens possivelmente relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas, as quais, todavia, por si só não permitiram concluir com exatidão o seu significado (fls. 167).

O órgão do Ministério Público apontou, dentre os arquivos verificados no celular do menor, uma mensagem trocada entre ele e o réu pelo aplicativo Messenger, do Facebook, que seria indicativa de que se conheciam (fls. 198). De fato, eles se conheciam, como se extrai das circunstâncias da abordagem, mas do conteúdo da mensagem não se conclui, contrariamente ao quanto expedindo, que o réu vendia drogas na companhia do adolescente e que o “fazia em atividade estruturada do tráfico de drogas, inclusive com divisão de horários e escala própria entre os responsáveis por essa atividade criminosa, indicando sua habitualidade na dedicação ao crime e, ainda, envolvimento com a criminalidade organizada” (fls. 199), pois o só fato de o réu provavelmente conhecer o menor, ainda que tenha mentido a respeito, não é prova de que atua do mesmo modo que ele.

Ainda que as circunstâncias da abordagem do réu denotem que sua conduta não consistiu em mero e eventual transporte de drogas, não se pode validamente, apenas com base no conteúdo do celular do adolescente, concluir-se sobre o envolvimento do réu com a criminalidade organizada, com hierarquia e método, notadamente porque no

celular pertencente ao adolescente havia uma única mensagem que pode ter sido trocada com o réu - não havendo certeza de que ele era o interlocutor, pois o contato estava salvo como "Junior Alves", o que apenas parcialmente coincide com o do réu -, e o conteúdo da mensagem não é nem minimamente comprometedor, pois enviada ao adolescente apenas a mensagem "Bouaaa" (fls. 198).

De todo modo, o réu trazia consigo a significativa quantidade de 143 microtubos de cocaína e 39 porções de maconha com a evidente finalidade de venda a terceiros, o que se deduz não só de sua conduta suspeita, de buscar evitar a abordagem policial quando se encontrava em conhecido ponto de tráfico de drogas, como também por estar em poder da elevada quantia de R\$ 910,05, cujo alegado desconhecimento é risível.

Não por outra razão foi preso em flagrante (Auto de Prisão em Flagrante Delito a fls. 01) e a respeito de sua conduta foram lavrados Boletim de Ocorrência (fls. 02/06) e Auto de Exibição e Apreensão (fls. 18/19), este relacionado à apreensão de um telefone celular da marca Samsung e de R\$ 30,00 em poder do adolescente, e à apreensão de R\$ 910,05 (comprovações de depósito judicial a fls. 224/225 e fls. 62, respectivamente) e das drogas (143 microtubos de cocaína e 39 porções de maconha) em poder do réu.

Tanto preliminarmente (Laudo de Constatação Provisória de Entorpecente a fls. 22/24) como definitivamente (Laudo de Exame Químico-Toxicológico a fls. 179/181) identificou-se que as drogas apreendidas em poder do réu tratavam-se, efetivamente, de 83,66g de cocaína e 259,72g de maconha. Além disso, os entorpecentes estavam embalados individualmente e prontos para comercialização (fls. 04).

Não remanescem dúvidas, portanto, sobre a autoria e a materialidade delitivas acerca do crime de tráfico de drogas, comprovadas pelas provas produzidas, estas corroboradas pela confissão do réu.

Na pochete dispensada pelo réu e igualmente apreendida também havia uma munição de arma de fogo, a respeito da qual ele também alegou desconhecimento.

Periciada, constatou-se que a munição estava íntegra e eficiente para produzir disparos, sendo compatível com pistola semiautomática de cal. 9mm (Laudo Pericial de Exame de Peça a fls. 177/178).

Conquanto atestada a potencialidade lesiva da munição, o réu estava ilegalmente em poder de apenas uma única munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo. Embora haja divergências jurisprudenciais a respeito, é sabido que o E. Superior Tribunal de Justiça e o E. Supremo Tribunal Federal passaram a admitir a aplicação do princípio da insignificância em casos análogos, ainda que haja condenação por outro crime, desde que apreendida pequena quantidade de munição sem que, conjuntamente, tenha sido apreendida arma de fogo, em situação a ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, seguem jurisprudências nas quais se reconheceu a atipicidade da conduta por mínima lesão ao bem jurídico tutelado, incapaz de tipificar o crime previsto no Estatuto do Desarmamento, mantida, porém, a condenação pelo crime de tráfico de drogas:

TRÁFICO DE DROGAS - Apelos da Defesa e da Acusação - Prova bastante segura - Relatos dos policiais seguros e coerentes - Negativas dos réus frágeis e isoladas - Condenação de rigor - Dosimetria - Penas dosadas com critério e equilíbrio - Natureza da substância estupefaciente nada incomum - Privilégio cabível aos agentes primários, com substituição da pena por Restritiva de direitos e adoção do regime aberto - Corréu reincidente específico - Figura privilegiado inaplicável - Regime fechado necessário. Porte ilegal de munição - Apreensão de quantidade nada

significativa - Atipicidade reconhecida - Precedentes - Absolvição bem decretada. Recursos parcialmente providos (TJSP - APR: 15020022820198260542 SP 1502002-28.2019.8.26.0542, Relator: André Carvalho e Silva de Almeida, data de julgamento: 13/05/2022, 2ª C. de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/05/2022). Grifou-se.

PENAL E PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, RECEPÇÃO E PORTE DE MUNIÇÕES. AUSÊNCIA DE ARMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARTEFATO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. ENTENDIMENTO QUE NÃO PODE LEVAR À PROTEÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. POSSE DE 3 (TRÊS) MUNIÇÕES CALIBRE .38 DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Não há se falar em atipicidade em virtude da apreensão da munição desacompanhada de arma de fogo, porquanto a conduta narrada preenche não apenas a tipicidade formal mas também a material, uma vez que "o tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal" (AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 4/2/2016). Nesse contexto, verifico que permanece hígida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta. 3. Passou-se a admitir, no entanto, a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes do STF e do STJ. 4. A possibilidade de incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão. Com efeito, analisando os precedentes, verifico que a insignificância se apresenta em situações nas quais se portava de 1 a 7 munições. Outrossim, a Quinta Turma já considerou que a apreensão de 20 projéteis não autorizava a aplicação do mencionado princípio. 5. A situação apresentada está mais próxima das hipóteses em que se reconheceu a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, possuindo, assim, a nota de excepcionalidade que autoriza a incidência do referido princípio, porquanto apreendidos 3 (três) cartuchos de calibre .38, desacompanhados de arma de fogo. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para absolver o paciente pelo crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, mantendo-se intacta a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. (STJ - HC: 526635 SP 2019/0237596-9, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 24/09/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 04/10/2019). Grifou-se.

Outrossim, de acordo com as teses do E. Superior Tribunal de Justiça sobre o Estatuto do Desarmamento, publicadas na edição n. 108, de 24 de agosto de 2018: "2) A apreensão de ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, excepcionalmente, a depender da análise do caso concreto, pode levar ao reconhecimento de atipicidade da conduta, diante da ausência de exposição de risco ao bem jurídico tutelado pela norma. Julgados: REsp 1735871/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018; HC 442036/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018; AgRg no HC 440820/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018; AgRg no REsp 1733440/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018; HC 430276/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018,

DJe 30/05/2018; REsp 1654386/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018.".

Verificando-se que o réu foi abordado com apenas uma munição, desacompanhada de arma de fogo que pudesse deflagrá-la, a situação oferece mínima lesividade à norma jurídica. Some-se à análise a ausência de registros criminais por parte do réu, inclusive quando menor de idade (Certidão da Vara da Infância e Juventude a fls. 68), sendo o reconhecimento da atipicidade da conduta medida que se impõe, aplicando-se ao caso o princípio da insignificância, com a consequente absolvição.

Sendo caso de condenação pelo crime de tráfico de drogas, procedo à dosimetria das penas com atenção ao disposto no art. 68 do Código Penal.

O réu não ostenta antecedentes desabonadores (Certidão Estadual de Distribuições Criminais a fls. 67 e Folha de Antecedentes a fls. 69/70). No entanto, estava em poder de 39 porções de maconha, com peso líquido total de 259,72g, e de 143 microtubos de cocaína, com peso líquido total de 83,66g, sendo considerável a quantidade de drogas apreendida, além de serem estas de qualidades diversas, ou seja, maconha e cocaína, esta última substância entorpecente cujos efeitos deletérios sobre o organismo humano são muito mais drásticos do que o de outras substâncias de uso proscrito no Brasil, sendo mais grave, portanto, a potencialidade lesiva da conduta, porque agravado o risco à saúde pública.

Nesse contexto, em atenção às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal e àquelas enumeradas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, à vista da preponderância do caráter de maior lesividade da conduta, fixo as penas-base um sexto acima dos mínimos legais, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

O réu confessou a posse das drogas e assinalou que as transportaria. Portanto, ainda que não tenha confirmado a destinação das drogas ao fornecimento ao consumo de terceiros, confessou a prática de conduta que igualmente está tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/06, ou seja, confessou o tráfico, tal como descrito na denúncia, devendo incidir a atenuante da confissão (Código Penal, art. 65, inc. III, 'd'), porquanto "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (STJ, Súmula 630), razão pela qual reduzo as penas de um sexto, com limitação aos mínimos legais de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, ante a impossibilidade de que atenuantes reduzam as penas aquém de sua cominação abstrata mínima (STJ, Súmula 231: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

Não há agravantes a considerar.

Considerando que o réu é primário e não ostenta antecedentes desabonadores, e tendo em conta que não há evidência de que integre organização criminosa ou de que se dedique a atividades criminosas, ainda que, contrariamente ao quanto aduziu, já estivesse envolvido com a traficância há algum tempo, o que se deduz do expressivo valor de numerário que trazia consigo, deve incidir a causa especial de diminuição de penas preconizada na Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º, e não há motivação suficiente para que o quantum de redução não seja o máximo legalmente admitido, inclusive em prestígio à sua atitude parcialmente colaborativa em juízo, razões para que as penas sejam reduzidas de dois terços, as quais, à ausência de outras causas de modificação, são tornadas definitivas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da vedação constante da parte final do § 4º do art. 33 Lei nº 11.343/06, e suspensa pela Resolução nº 5, de 16/02/2012, do Senado Federal, a execução da expressão vedada a conversão em penas restritivas de

direitos constante do mesmo dispositivo, inexistindo óbice legal à substituição, por pena restritiva de direitos, da pena privativa de liberdade, a qual não suplanta quatro anos.

Atendidos os requisitos dos incisos I a III do art. 44 do Código Penal, de acordo com a parte final do § 2º do mesmo dispositivo legal substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser paga a entidade pública ou privada com destinação social e sede nesta Cidade, a critério do Juízo sucessivo da Execução (Código Penal, art. 45, § 1º), e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, igualmente a critério do Juízo sucessivo da Execução, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, pelo prazo desta última (Código Penal, art. 46, §§ 1º a 4º), observada a detração penal.

A respeito da fixação do regime inicial de cumprimento de pena para a hipótese de conversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade (Código Penal, art. 44, § 4º), observa-se que o STJ, ao julgar a Questão de Ordem na Pet 11.796-DF, afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema 600), na sessão de 23/11/2016 firmou a tese de que “o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo” (Pet 11.796/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 29/11/2016).

Também a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (denominado Pacote Anticrime), incluiu o § 5º no art. 112 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), que trata da progressão de regimes durante a execução das penas privativas de liberdade, o qual passou a dispor que “não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”.

À vista do exposto, a fixação do regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser feita com base nas normas gerais estabelecidas no Código Penal (e não se olvidando do quanto determinado no Habeas Corpus nº 596.603, Rel. o Ministro Rogério Schietti Cruz), razões pelas quais, atendidos os pressupostos legais, fixo o regime inicial aberto de cumprimento de pena para a hipótese de conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade (Código Penal, art. 33, § 2º, 'c').

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva e:

i) absolvo Luiz Fernando Júnior Alves dos Santos da acusação de incursão no art. 14 da Lei nº 10.826/03, o que faço com fundamento no art. 386, inc. III do Código de Processo Penal;

ii) condeno Luiz Fernando Júnior Alves dos Santos à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, a ser paga a entidade pública ou privada com destinação social e sede nesta Cidade, e em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo prazo da condenação, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; condeno-o, igualmente, à pena pecuniária de 188 dias-multa, com cálculo da unidade destes no piso legal, por incursão no art. 33, caput, c.c. o respectivo § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (Código de Processo Penal, art. 804), no valor equivalente a cem UFESPs (Lei Estadual 11.608/2003, art. 4º, §9º).

Como efeito desta sentença condenatória determino a perda, em favor da União, do

dinheiro apreendido em poder do réu, porque não se comprovou tenha origem lícita, devendo ser considerado produto do narcotráfico (Código Penal, art. 91, inc. II, 'b', e Lei nº 11.343/06, art. 63, inc. I).

O réu foi preso em flagrante e permaneceu recolhido ao cárcere no decorrer do processo porque se faziam presentes os requisitos da prisão preventiva. Presentemente, condenado a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, não há razoabilidade em que seja mantida sua custódia, pois importaria na permanência do réu em regime fechado, mais gravoso do que aquele imposto por esta sentença, a caracterizar desproporcionalidade.

Frente ao exposto, expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Ao trânsito em julgado:

i) lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados;

ii) expeça-se guia de recolhimento;

iii) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins da Constituição Federal, art. 15, inc. III;

iv) intime-se o réu para pagamento da multa penal imposta, no prazo de dez dias (Código Penal, art. 50, caput, e Código de Processo Penal, art. 686), e para pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a cem UFESPs, no prazo de sessenta dias;

v) oficie-se à Senad, encaminhando-lhe informação sobre o valor de R\$ 910,05, declarado perdido em favor da União (Lei nº 11.343/06, art. 63, §4º), objeto do auto de fls. 18/19 e do depósito de fls. 62 e 101.

Sem prejuízo, desde já atenda a Serventia à solicitação do E. Juízo da Vara da Infância e Juventude desta Comarca, providenciando a transferência do numerário apreendido com o adolescente para os autos nº 1519296-67.2021.8.26.0625, daquele Juízo (ofício a fls. 221 e documentos de fls. 222/225).

Publique-se.

Intimem-se.

Taubaté, 23 de maio de 2022.

Cláudia Calles Novellino Ballesterio
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA